

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0043350-92.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LUCAS GOMES PEREIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **André Luiz da Silva da Cunha**

Vistos.

LUCAS GOMES PEREIRA foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 24 de maio de 2017, por volta das 16 horas, na Rua Estrela Azul, nº 04, nesta Capital, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 235 porções de cocaína, pesando 45,4 gramas, e 10 porções de maconha, com peso líquido de 19,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na ocasião dos fatos, policiais civis, movidos por notícia anônima, foram até conhecida área de traficância e avistaram o réu parado em frente a um imóvel. Os policiais revistaram o acusado e com ele encontraram porções de maconha, além de R\$ 212,00 em espécie. Inquirido informalmente, **Lucas** confessou a traficância e autorizou que os policiais ingressassem em sua casa. Após revistar o imóvel, os agentes públicos localizaram as porções de cocaína, além de um caderno com anotações com a contabilidade do tráfico.

A denúncia foi recebida em 21 de junho de 2017 (fls. 99/100).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, pela fixação de pena no mínimo legal, aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, regime aberto e concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o **relatório**.

Fundamento e decido.

A pretensão veiculada nesta ação é **procedente**.

A materialidade do crime encontra-se consubstanciada no auto de prisão em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

flagrante, no boletim de ocorrência, no laudo de constatação prévia e no laudos periciais de fls. 111/113 e 114/117, tendo estes últimos documentos atestados que no material apreendido havia presença de *tetrahydrocannabinol* e *cocaína*, substância prevista na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do réu.

Na Delegacia de Polícia, **Lucas** confessou a prática do crime. Relatou que estava no local para vender drogas e que receberia a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia (fl. 08).

Em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, o réu negou a prática do crime. Afirmou que trabalha e que, na data dos fatos, havia acabado de sair do seu trabalho. Quando desceu um viaduto viu uma movimentação. Pouco tempo depois, foi abordado por policiais militares da Força Tática. Disse que estava sem seus documentos e que os policiais foram até sua residência para buscá-los. Disse todas as pessoas que estavam sendo abordadas fugiram. Em um terreno ao lado de sua residência foram encontradas drogas.

Ocorre que a negativa apresentada pelo réu restou absolutamente isolada nos autos.

Os policiais civis Josemeire Inácio de Almeida e José Wilson Ferreira Lima disseram que em diligências para apurar notícia da ocorrência de tráfico ilícito de drogas, avistaram o réu parado na frente de um imóvel. Em revista pessoal, encontraram com ele algumas porções de maconha, além de dinheiro em espécie. Conversaram com o acusado e ele confessou que estava ali para vender entorpecentes, justificando que se encontrava desempregado. O réu lhes disse, ainda, que havia mais drogas no interior do imóvel. Ingressaram na residência e localizaram grande quantidade de cocaína.

De se destacar que narrativa segura e coesa apresentada pelos policiais na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária. Esta circunstância dá ainda mais credibilidade aos relatos.

Impende registrar que a condição de policial e o simples fato de ter participado da ocorrência que culminou na prisão do acusado, não torna a testemunha suspeita ou impedida. Seria absurdamente incoerente atribuir a estes agentes a função de reprimir infrações penais, mas considerá-los suspeitos no momento em que fossem testemunhar fatos relativos as suas atribuições.

Os atos de todos servidores públicos possuem fé pública. Não se pode, aprioristicamente, negar qualquer valor ao testemunho de agentes policiais por preconceituosa presunção de que não dizem a verdade.

Não se ignora que, com infeliz frequência, policiais civis e militares agem de forma abusiva e arbitrária. Porém, nada há nos autos que possa nos fazer duvidar da conduta do policial ouvido em juízo.

Ademais, pelo que se apurou, antes da prisão os policiais não conheciam o réu e nada tinham contra ele. Não teriam, portanto, motivos para mentir apenas para prejudicá-lo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

No mais, impende frisar que o réu confessou espontaneamente a prática do crime na Delegacia de Polícia. A confissão extrajudicial foi ampla e detalhada. Não parece crível que tenha sido *inventada* pelos policiais.

Assim, o réu foi encontrado na via pública, com dinheiro trocado em espécie e 10 (dez) porções de maconha. Além disso, em imóvel que estava sob sua guarda e responsabilidade, guardava 235 (duzentos e trinta e cinco) porções de cocaína. Não bastasse, na abordagem policial e na Delegacia de Polícia confessou espontaneamente a prática do crime.

Por todas estas razões, cabalmente comprovado que **Lucas** praticou o crime que lhe é imputado.

Passo à dosimetria da pena.

A Constituição Federal erigiu como fundamental o direito à individualização da pena. É o que dispõe o art. 5º, XLVI, do citado diploma. Esta individualização consiste em operação que tem por finalidade eleger a reprimenda justa e adequada ao caso concreto. Muito mais que um dever do magistrado, a norma insculpida neste dispositivo constitucional estabelece um direito fundamental do ser humano, o de não ser submetido a uma pena padronizada ou mecanizada.

Em respeito a este preceito fundamental, é de suma relevância que o julgador faça uma minuciosa análise de todos os elementos existentes nos autos, referentes ao fato criminoso praticado pelo agente, bem como ao agente que praticou o fato criminoso.

Feita esta observação, inicio a individualização da reprimenda penal.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis ao acusado.

O réu foi surpreendido com menos de 70 gramas de drogas, quantidade que não se revela suficiente o bastante para justificar maior censura de sua conduta, visto não destoar da quantia comumente apreendida em situações semelhantes. Importante frisar que este é o entendimento do Tribunal de Justiça local. Destaco os seguintes julgados, onde podemos constatar agentes surpreendidos com quantidades de entorpecentes muito superiores à verificada no presente caso tiveram a pena-base fixada no piso legal:

Tráfico de entorpecente. Réu detido em flagrante na posse de 157,8 gramas de cocaína (163 porções), 60,5 gramas de crack (107 porções) e 38,2 gramas de maconha (56 porções). Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Autoria e materialidade quanto ao tráfico evidenciadas. Reforma das penas. Bases fixadas acima dos mínimos legais pela quantidade e natureza de droga. Reincidência. Entretanto, ausência de fundamentação quanto à comprovação da reincidência. Juíza sentenciante que não apontou a certidão que teria se baseado. Promotor silente. Verifica-se nos autos a juntada de mera folha de antecedentes. F.A. não é documento hábil a comprovar reincidência. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido e aplicado à fração de um sexto. Regime semiaberto. Parcial provimento. (TJ/SP. Apelação 0010231-73.2014.8.26.0268. 16ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Guilherme de Souza Nucci. Julgado em 16.02.2016)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Recurso exclusivo da acusação visando o acréscimo da pena e imposição de regime semiaberto. – Escorreta a condenação. Prisão em flagrante delito. Apreensão de 500g (quinhentos gramas) de cocaína na


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

posse do réu. Versão de que era para o próprio o consumo não convenceu. Relatos insuspeitos dos policiais confirmaram a acusação. Mantidas a condenação. A pena comporta redução. Réu primário e de bons antecedentes. Nada comprova envolvimento com organização criminosa. Pena-base no mínimo legal. Circunstância atenuante (menor de 21 anos de idade) prejudica. Aplicação da Súmula nº 231 do STJ. Quantidade e qualidade de drogas (Art. 42 da Lei Antitóxicos) não é incompatível com a aplicação do fator redutor (parágrafo 4º do art. 33). Redução de 1/3 (um terço) considerando a quantidade e qualidade de drogas. Mantido regime semiaberto dado o "quantum" de pena aplicado e as diretrizes das Súmulas 718 e 719 do STJ. Não recomendável a aplicação da substituição da pena carcerária por restritivas de direitos. - Recurso da acusação provido, em parte, para reduzir a pena imposta. (TJ/SP. Apelação 0004717-89.2014.8.26.0220. 1ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Péricles Piza. Julgado em 09.11.2015)

A natureza dos entorpecentes não permite exasperar a pena. Existem diversas outras drogas muito mais lesivas à saúde humana, como o *oxi*, a *metanfetamina* e a *heroína*.

Não há *variedade* de drogas, sendo o acusado preso com apenas dois tipos de estupefaciente.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo também são favoráveis ao denunciado.

Ele não registra maus antecedentes. Existe um único apontamento em sua ficha criminal, referente ao presente processo. Assim, de se concluir que o evento delitivo em questão foi um evento episódico na sua vida. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade.

A culpabilidade externada pela prática do crime não se mostrou acentuada. As circunstâncias, consequências e motivos são absolutamente normais à espécie, de forma que a reprovabilidade do comportamento do agente não extrapolou o que já punido pelos tipo penal.

Destarte, as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, e art. 42, da Lei de Drogas, são inteiramente favoráveis ao réu, não havendo nenhuma peculiaridade no presente caso que possa justificar a elevação da sanção nesta primeira fase, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presente as atenuantes prevista no art. 65, I, e III, *d*, do Código Penal, pois **Lucas** tinha apenas 20 (vinte) anos na data do crime e, aos policiais militares e na Delegacia de Polícia, confessou espontaneamente a sua prática.

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive cristalizado no enunciado sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase da dosimetria, as circunstâncias legais não devem conduzir a pena para alguém ou além dos limites abstratamente cominados pelo legislador. No presente caso, as penas-base foram fixadas no piso legal. Diante disto, em respeito ao citado entendimento jurisprudencial, deixo de considerar, na dosimetria da pena, as citadas atenuantes.

Não se configurou nenhuma causa de aumento de pena. Por outro lado, verifica-se que o acusado é primário e ostenta bons antecedentes criminais. Nada há nos autos que possa indicar que se dedique a atividades criminosas, nem tampouco que integre organização desta



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

natureza. Assim sendo, possível a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ao estabelecer esta minorante, o legislador previu uma redução variável, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Não previu, no entanto, os critérios que deveriam ser considerados para a escolha do *quantum* de redução.

Não obstante a omissão legislativa, entendo que, em homenagem ao princípio da individualização da pena, e tendo sempre como norte as finalidades da sanção penal, relevantes circunstâncias relativas ao fato criminoso e ao agente devam ser consideradas na escolha do montante de diminuição.

Tendo em vista a nada expressiva quantidade de entorpecente e a total ausência de elementos que permitam aferir o período em que o réu participava da narcotraficância, não vejo óbice para a aplicação da fração máxima de redução, qual seja, 2/3 (dois terços).

Desta feita, **torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.**

Ao que consta, o acusado não goza de padrão de vida elevado. Por esta razão, considerada sua presumível situação econômica, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Estabelecido o *quantum* da reprimenda penal, passo à análise do regime prisional.

Inicialmente, importante salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento no Habeas Corpus nº 118.533/MS, entendeu que **o denominado tráfico privilegiado, hipótese dos autos, não tem natureza hedionda.** Decidiu nossa Corte Suprema:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. (HC 118533. Tribunal Pleno. Rel. Cármen Lúcia. Julgado em 23/06/2016. DJe 16/09/2016).

Portanto, estamos diante de crime comum.

Pois bem. Prescreve o art. 33, § 2º, c, do Código Penal que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O § 3º, do mesmo dispositivo, estabelece que o regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Diante destes dispositivos, a jurisprudência, de forma pacífica, exige coerência


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do juízo sentenciante ao estabelecer a pena-base e fixar o regime de cumprimento de pena, visto que ambas as providências têm como diretrizes as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Na espécie, a pena-base do acusado foi fixada no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Trata-se de pessoa absolutamente primária, sem nenhum outro envolvimento criminal. A pena ficou abaixo de 04 (quatro) anos. *In casu*, nenhum elemento concreto justifica a imposição de regime mais severo que o indicado pelo legislador, diante da pena concretamente aplicada.

Impende registrar que há muito se repudia a fixação de regime mais severo que o adequado de acordo a pena aplicada com fundamento na gravidade em abstrato da infração. Apenas circunstâncias fáticas que transbordem a normalidade do tipo penal podem justificar o episódico afastamento das diretrizes previstas no art. 33, §2º, do Estatuto Repressivo.

No mais, invocar a gravidade abstrata do delito, neste momento, atentaria contra o princípio constitucional da individualização da pena. O regime prisional para início do cumprimento da sanção seria fixado não em razão das circunstâncias do caso singularizado, mas tão somente em virtude da prática de um delito que, na visão do julgador, é genericamente grave.

Este entendimento está cristalizado na Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal: *“A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo que o permitido segundo a pena aplicada”*.

Sobre o tema, temos ainda a Súmula nº 440, do Superior Tribunal de Justiça: *“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”*.

Nesse contexto, pelas razões expostas, fixo o regime prisional **aberto** para início do desconto da pena.

O réu é primário e ostenta bons antecedentes. O crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. A pena privativa de liberdade ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Não agiu o acusado com acentuada culpabilidade. Por fim, como já afirmado, não existem elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade.

Logo, todos os requisitos, objetivo e subjetivos, previstos no art. 44, do Código Penal, estão preenchidos. Em razão disto, substituto a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da pena, e multa, que fixo em 10 (dez) diárias, no piso legal.

Isto posto, julgo a presente ação penal **PROCEDENTE** para condenar **LUCAS GOMES PEREIRA**, como incurso no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de **01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão**, no regime inicial **aberto**, e ao pagamento de **166 (cento e sessenta e seis) dias-multa**, no mínimo legal. A reprimenda corporal fica substituída por pena restritiva de direito e multa, na forma acima estabelecida.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do valor monetário

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apreendido em favor do FUNAD.

Em obediência ao disposto no art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESPs. Porém, tendo em vista sua parca situação financeira, concedo os benefícios da justiça gratuita, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

São Paulo, 01 de novembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**